

学生A及びBは、次の【事例】における甲の罪責について、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの（ ）内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑤までの（ ）内にはそれぞれ異なる語句が入る。

【事例】

甲は、殺意をもって、Xの腕の静脈内に蒸留水と空気を注射したが、当該空気量が疾病のない健康人に対する致死量未満であったためXは死ななかった。また、甲は、当該空気量が上記致死量未満とは知らなかった。なお、当該空気量であっても被注射者の身体的条件等によっては死亡する危険はあった。

【会話】

学生A. 未遂犯と不能犯の区別に関してはいろいろな考え方がありますが、行為の時点において一般人が認識し得た事情と行為者が特に知っていた事情を基礎とし、一般人が結果発生を感じる場合には可罰的未遂を肯定する考え方に立ち、本事例では一般人が結果発生を感じる危険を感じるとすれば、甲に殺人未遂罪が(①) こととなりますね。

学生B. この考え方に対しては、(②) ことになるという批判がありますね。では、結果発生危険性を事後的客観的に判断する考え方に立った場合、甲の罪責をどう考えますか。

学生A. (③) という考え方によれば、身体的条件等によっては死亡の危険があったので、甲に殺人未遂罪が成立します。一方で、結果発生危険性を事後的客観的に判断する考え方を徹底すれば、(④) ことになりませんか。

学生B. そうとは限りませんよ。結果が発生しなかった原因究明と同時に、いかなる事情があれば結果発生があり得たかを明らかにし、(⑤) 可能性を判断すれば妥当な結論を導けます。

【語句群】

- a. 成立する b. 成立しない c. 迷信犯に未遂犯を認める
- d. 印象で未遂犯処罰を決める
- e. 行為者の認識内容が客観的真実に合致するか否かによって区別する
- f. 結果発生絶対的不能・相対的不能によって区別する
- g. 行為者の誤信が相当と認められる
- h. 結果発生をもたらす仮定的事実が存在し得た
- i. 結果不発生の原因を解明できた場合、すべて不能犯となる

1. ①a ②c ③e ④g ⑤h
2. ①a ②d ③f ④i ⑤h
3. ①a ②e ③f ④c ⑤g
4. ①b ②d ③e ④i ⑤g
5. ①b ②i ③f ④c ⑤g

No141	未遂犯と不能犯の区別	正答率
共通R5-7	正解 2	96%

() には順に、「① = a、② = d、③ = f、④ = i、⑤ = h」と入り、したがって、正解は肢2となる。

①、②について

未遂犯と不能犯の区別基準について学生Aは、「行為の時点において一般人が認識し得た事情と行為者が特に知っていた事情を基礎とし、一般人が結果発生危険を感じる場合には可罰的未遂を肯定する考え方」に立つと発言しているので、いわゆる具体的危険説と呼ばれる見解を前提としていと考えられる。そして、この具体的危険説を前提とすると、本問事例においては、行為の危険性判断の基礎事情として、甲は、Xの腕の静脈内に蒸留水と空気を注射しており、一般人はその事実を認識し得たといえるので、当該事情を基礎とすることとなる。他方で、本問事例においては、注射した空気量が致死量未満であったので、当該事情を前提とすると殺人罪の危険性なしと判断する余地も出てくるが、行為者である甲は、行為時に当該事情を認識しておらず、一般人も行為時に認識し得たとはいえないので、危険性判断の事情とすることはできない。よって、甲がXの腕の静脈内に蒸留水と空気を注射したという事情をもとに、当該行為が殺人罪の結果発生危険を一般人が感じるかどうかを考えると、腕の静脈内に蒸留水と空気を注射するという行為は、死亡結果発生危険を一般人は感じるといえる。そして、本事例においては、死亡結果は発生しなかったため、甲に殺人未遂罪(199条、203条)が成立する。したがって、①には「a. 成立する」が入ることになる。

このような具体的危険説に対しては、行為の危険性判断において、一般人の危険感を基準とする点において、基準が曖昧であるという批判がある。例えば、ある薬品を飲ませたようなケースで考えてみると、薬品の毒性に関する知識については、一般人の間でも様々であり、一般人の判断も分かれることとなる。また、仮に科学的にその薬品の毒性が無視しても良いほどに弱いものであったとしても、一般人の印象として毒性が強いということになれば、危険性が肯定されることとなってしまふ。このように、一般人の危険感という判断基準で行為の危険性を判断する以上、一般人の認識によって判断が割れることになり、印象で未遂犯処罰を決めることとなるという批判が成り立つ。したがって、②には「d. 印象で未遂犯処罰を決める」が入る。

③、④、⑤について

結果発生危険性を事後的客観的に判断する考え方である客観説の中でも、行為時の全事情を基礎に、行為を事後的に観察し、その客体または手段の性質からみて結果の発生が絶対的に、すなわちいかなる場合にも不能なときを不能犯、結果発生が相対的に不能であった場合を未遂とする見解がある。本問事例においては、Xが注射した空気量は致死量未満であったという事情があるが、被注射者の身体的条件等によっては死亡する危険はあったので、いかなる場合にも不能とはいえず、殺人罪の結果発生危険性は認められる。よって、この見解によると甲に殺人未遂罪(199条、203条)が成立することになる。したがって、③には「f. 結果発生絶対的不能・相対的不能によって区別する」が入る。

これに対して、客観説を徹底した場合、行為後の事情まで含めて事後的に純科学的に危険性を判断する見解(純粹客観説と呼ばれたりする)につながるようになるが、このような見解は事後的な検証によって結果不発生の原因が解明できれば、全て不能犯になってしまうという批判がある。したがって、④には「i. 結果不発生の原因を解明できた場合、すべて不能犯となる」が入る。

このような客観説への批判に対応して、修正された客観的危険説といわれるものが提唱されている。これは、結果を発生させるために必要であったが、存在しなかった事実(仮定的事実と呼ぶ)

の存在可能性の程度を、一般人を基準として事後的に問うことにより危険の有無を判断するという見解である。このような見解によると、本問事例では、Xに注射された空気量が致死量未満という事情によって、殺人罪の結果発生は惹起されなかったが、「当該空気量であっても被注射者の身体的条件等によっては死亡する危険はあった」（仮定的事実が存在し得た）ことから、殺人罪の結果発生の危険性が肯定され、殺人未遂罪が成立し得るという妥当な結論を導ける。したがって、⑤には「h. 結果発生をもたらす仮定的事実が存在し得た」が入る。

なお、最判昭 37.3.23（百選 I 66 事件）は、「人体に空気を注射し、いわゆる空気栓塞による殺人は絶対に不可能であるというが、原判決並びにその是認する第一審判決は、本件のように静脈内に注射された空気の量が致死量以下であつても被注射者の身体的条件その他の事情の如何によつては死の結果発生の危険が絶対にないとはいえないと判示しており、右判断は、原判示挙示の各鑑定書に照らし肯認するに十分であるから、結局、この点に関する所論原判示は、相当である」として